

1501337-35.2019.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO DOS SANTOS LOPES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

FRANCISCO DOS SANTOS LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque no dia 28 de agosto de 2019, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501337-35.2019.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501337-35.2019.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO DOS SANTOS LOPES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

FRANCISCO DOS SANTOS LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque no dia 28 de agosto de 2019, por

volta de 21h10min, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Pantera", localizado na Avenida Rio das Pedras, nº 192, bairro Piracicamirim, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 14 (quatorze) invólucros plásticos transparentes, contendo cocaína, em sua formulação conhecida como "crack", com peso líquido aproximado de 1,2g (um grama e dois decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica.

O réu foi notificado por edital a apresentar sua defesa preliminar (fls. 64) tendo a peça defensiva sido apresentada pela defensoria pública fls. 76/78.

A denúncia foi recebida em 26/05/2020 (fls. 103), oportunidade em que o feito foi suspenso nos termos do artigo 366 do C.P.P. ante a não localização do acusado.

O réu foi localizado e citado pessoalmente em 19/06/2022 (fls. 148).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente, em parte.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, pelo laudo de constatação provisória de fls. 24, pelo comprovante de depósito de fls. 44, pelo laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 176/178 positivo para cocaína.

A autoria é certa, o que não se pode dizer da intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, optou por permanecer calado e somente se manifestar em juízo (fls. 06).

Em juízo, negou os fatos. Disse que capinou um terreno e recebeu R\$ 200,00 e adquiriu 14 porções de crack, que escondeu no calçado. Nesse momento foi abordado, mas não estava traficando. Não disse aos policiais que estava vendendo as drogas. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Nunca vendeu drogas.

E sua versão não foi afastada com a certeza necessária.

O guarda civil Paulo Franco Junior esclareceu que na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina e, quando se aproximaram do "Bar do Pantera", conhecido ponto de tráfico, percebeu que o réu, ao avistar a viatura policial, tentou se afastar do local. Diante da fundada suspeita, realizou a abordagem do acusado e, em revista pessoal, localizaram em seu bolso R\$ 80,00 em notas diversas. No tênis que o réu calçava encontraram 14 porções de crack. Indagado, o réu confessou que era usuário vendia a droga a R\$ 5,00 cada poção. Disse ainda que a cada kit de 28 porções vendidas, oito serviriam para seu consumo. Não presenciou o réu entregando drogas a outras pessoas.

No mesmo sentido o depoimento do guarda civil Joel Vasconcelos de Lima, que não se recordou da apreensão de dinheiro com o réu.

E a conduta dos guardas civis não se reveste de qualquer ilicitude, com reclamado pela defesa.

Isso porque o réu foi avistado em local conhecidíssimo por ser ponto de venda de drogas e, ao notar a aproximação da viatura, buscou se afastar do local, gerando fundada suspeita que permite sua abordagem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Abordagem e busca pessoal que estão justificadas, pois de acordo com a lei: fundada suspeita (art. 244 do CPP). Policiais que apontaram de forma segura que, ao visualizar a aproximação da guarnição, o acusado, que se encontrava sentado em uma guia num local conhecido como ponto de tráfico, adotou atitude evasiva, denotadora de fundada suspeita de que tivesse algo ilegal consigo. Desnecessidade, inclusive diante do encontro de drogas com ele e de ser desmentido quanto a estar em outro local, que os policiais expusessem de forma mais elaborada a suspeita que os levava à revista pessoal, que, bom que se diga, independe de mandado judicial e

pode ser realizada a qualquer momento, mesmo que não se trate de situação de flagrante (não há que se confundir busca pessoal com busca domiciliar). Expertise policial que merece ser prestigiada, assim como são os depoimentos dos agentes da lei. Prova segura da autoria e materialidade. Condenação bem aplicada, merecendo, a r. sentença, ser ratificada na forma do art. 252 do Regimento Interno inclusive no que tange à dosimetria, fixada com critério. Recurso não provido.” (TJSP - Apelação Criminal nº 1500559-92.2021.8.26.0535, Santa Isabel, rel. designado Des. Xisto Rangel, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 08/08/2022).

No entanto, temos que o réu foi visto pelos policiais defronte ao “Bar do Pantera”, conhecido ponto de venda de drogas da cidade, como ele mesmo admitiu. Também certo, pois admitido pelo acusado, que tinha ele consigo 14 porções de crack e oitenta reais em dinheiro.

Nenhum ato de venda de drogas foi presenciado pelos guardas civis, que apenas o abordaram porque ele tentou se afastar ao avistar a viatura.

E essa conduta, ou seja, a de buscar se livrar da ação policial, é comum não só em quem trafica, mas em quem tem drogas sob sua guarda para uso próprio.

O fato de o réu ter admitido informalmente aos agentes públicos que traficava para sustentar seu vício não foi repetida na delegacia de polícia ou em juízo, pelo que não passa de mero indício que, para ser acolhido, carece de corroboração pelos demais elementos de prova trazidos aos autos, o que não é o caso do presente feito. Assim sendo, de certo mesmo temos a posse de drogas por parte do acusado. E, não havendo elementos de prova a demonstrar, extirpe de dúvidas, a intenção de comércio, deve ser acolhida a versão do acusado.

De rigor, pois, a desclassificação de sua conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Tóxicos.

E não se venha falar na inconstitucionalidade da atuação dos guardas civis, eis que embora não tenham atuação de patrulhamento ostensivo, não podem se omitir ao se deparar com uma situação de flagrante delito.

Assim, ao constatarem a presença de pessoa postada em conhecidíssimo ponto de venda de drogas da cidade e que, diante da aproximação da viatura apresentava nervosismo incomum, agiram com correção, pelo que não há que se afastar a legalidade dessa atuação.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente. II - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal - aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. Incidência da Súmula 07/STJ.

Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no AREsp 1565524/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)

Também nesse sentido a posição adotada pelo Eg. TJSP:

“Não se ignora ter o constituinte originário pátrio estabelecido como função precípua das guardas municipais a proteção dos “bens, serviços e instalações” do Município, “o que, segundo Bulos, corresponde ao policiamento administrativo da cidade, para a proteção do patrimônio público contra a depredação dos demolidores da coisa alheia” (LENZA, Pedro. “Direito Constitucional Esquematizado” 13ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo, Saraiva, 2009- pag. 664, grifei).

Contudo, nos últimos anos, têm sido debatidos projetos de emenda à Constituição

destinados a ampliar as atribuições das Guardas Municipais, possibilitando-lhes também atuar em prol da segurança pública, de modo a auxiliar as sobrecarregadas Polícias Civil e Militar no combate à violência e criminalidade que assolam as cidades do país, algo ainda longe de ser aprovado, considerado o complexo procedimento legislativo especial necessário à alteração de texto constitucional. Diante disso é que, mais recentemente, aprovou-se a Lei nº 13.022/2014, a qual, em seu artigo 5º, IV, estabeleceu a possibilidade de a guarda civil “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social”, numa busca à otimização do serviço de segurança pública ainda conferido às Polícias Civil e Militar, especialmente.

Em outras palavras, a lei ordinária em destaque certamente não “dilatou” a atribuição conferida pelo Constituinte pátrio às guardas municipais (e nem poderia fazê-lo, sob pena de vício de inconstitucionalidade), ainda limitada à proteção do patrimônio público municipal e, indiretamente, da população que dele usufrua, apenas reconhecendo a possibilidade de colaboração da entidade com as instituições vocacionadas à segurança pública.

Traçado este panorama, convém ponderar que, se qualquer do povo está autorizado a prender pessoa surpreendida em situação de flagrante por permissivo legal (artigo 301 do CPP) -, nada impede a concretização da custódia por integrantes da guarda municipal, sobretudo diante do papel recentemente atribuído à instituição no auxílio eventual dos órgãos de segurança pública, para garantir a paz social. Como já se decidiu, “É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal” (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019)” (STJ, HC 525772/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24-10-2019).”

(TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal - Habeas Corpus Criminal nº 2123003-60.2020.8.26.0000 – Relator Des. Farto Salles - J. 17/06/2020).

Por fim, não há se falar na inconstitucionalidade do previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos, nos termos do já decidido pelo Eg. TJSP:

“Ora, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei de Drogas. Referido tipo penal busca coibir a difusão da droga, resguardando a saúde pública (...) Desta forma, não merece amparo o pedido da defesa de declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, por não existir afronta a quaisquer dos princípios constitucionais. Ressalte-se que esta norma penal tutela a saúde coletiva, e não somente a saúde do próprio usuário de drogas, razão pela qual não é possível se falar em irrelevância penal, nem tampouco que a conduta seja tolerada pela sociedade. Ainda que se admita que a posse de entorpecentes para consumo pessoal seja uma conduta de ínfimo potencial ofensivo, ela encontra-se tipificada como criminosa no artigo 28, da Lei de Drogas. Referido artigo, como dito alhures, tutela a saúde pública, e não o prejuízo que a droga possa ou não causar. Ademais, a mera disponibilidade de substâncias entorpecentes proibidas gera risco de perigo à coletividade. Frise-se que o sujeito passivo é a própria sociedade, o que torna inadmissível a tese de que o porte para uso próprio seria apenas e tão somente uma autolesão. Caso assim o fosse, não seria tutelada pelo Direito Penal” (TJSP, APELAÇÃO nº 0011175-81.2012.8.26.0127, Rel. Des. Antônio Carlos Machado de Andrade, m 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 05.10.2017, Publicado em 10.10.2017).

E a surrada questão acerca da constitucionalidade da infração prevista pelo artigo 28 da Lei 11.343/06 já foi dirimida pelo Col. Supremo Tribunal Federal na questão de ordem no R.E. 430.105/RJ (julgado em 13/02/2007), onde se estabeleceu que o porte de drogas para uso próprio, embora tendo sido despenalizado pela Nova Lei de Tóxicos, não foi descriminalizado. Assim, afastada fica a arguição da defesa nesse sentido.

Da mesma forma, não deve vingar a tese que busca a aplicação do princípio da insignificância ou da adequação social.

Não se pode esquecer que não apenas o usuário é afetado pelo consumo de drogas, mas

toda a sociedade. O Estado dispende consideráveis recursos para tratamento dos efeitos do consumo de droga, valores esses desviados do tratamento de outras moléstias que atingem a população.

Assim, além de fomentar o tráfico, o consumo de drogas afeta a população como um todo.

“Malgrado tenha o legislador, com a edição da Lei 11.343/06, adotado novo enfoque criminológico no combate à infração de posse de drogas para consumo próprio, buscando reprimi-la por meio da aplicação de sanções mais brandas para os respectivos agentes, excluída a pena de privação da liberdade, tal não significa que as condutas previstas no tipo penal correspondente deixaram de ensejar a intervenção do Direito Penal, notadamente porque não há como adjetivar de insignificante a conduta de portar drogas, cuja natureza, em última análise, é a de fomentadora da gravíssima conduta de tráfico de drogas, verdadeiro flagelo das sociedades contemporâneas. E, em que pese o aparecimento, na última década, de algumas decisões no sentido preconizado pelo i. Defensor Público, o certo é que elas não representam uma tendência da jurisprudência brasileira, compondo um pequeno bloco de decisões proferidas em casos especiais, que refletem o interesse de evitar a intervenção penal nas situações em que o bem jurídico tutelado pelos tipos penais protegidos pelas Leis 6.368/76 e 11.343/06 (“saúde pública”) são afetados de modo quase imperceptível pela sociedade. No caso presente, em que o sentenciado foi surpreendido na posse de quantidade de “maconha” equivalente a uma porção individual, tem-se que ele, de fato, praticou conduta ofensiva ao bem jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei 11.343/06, qual seja a “saúde pública”, que não pode ser considerada insignificante sob qualquer aspecto, como acertadamente ressaltado na r. decisão hostilizada”(TJSP, Apelação nº 0018686-56.2014.8.26.0032, Relator Des. Otavio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 20.09.2017, publicado em 02.10.2017).

De rigor, pois, a parcial procedência da ação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é primário, pelo que suficiente a admoestação acerca dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu FRANCISCO DOS SANTOS LOPES - (RG: 34.931.933, filho de Antonio Juvino Lopes e Maria de Fatima dos Santos Lopes) a ser advertido acerca dos efeitos nocivos das drogas, como incurso no artigo 28, “caput”, da Lei nº. 11.343/06.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

P.I.C.

Piracicaba, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA